

1501153-45.2020.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa pediu a absolvição, sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado. No caso de condenação, a aplicação do privilégio.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501153-45.2020.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2222880/2020 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 13478858 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2594/20/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2222880 - 02º D.P. PIRACICABA, 2594/20/922 - 02º D.P. PIRACICABA, 2222880/2020 - 02º D.P.

PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO MAXIMIANO

Contr. nº 2020/001035

Aos 14 de julho de 2022, às 13:30 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). José Eduardo de Souza Pimentel foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu CARLOS EDUARDO MAXIMIANO. Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PMS GRAZIANO CIOLA DIAS e Carlos Alberto Morasco

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala,

inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (PM Carlos e PM Graziano) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a).1. CARLOS EDUARDO MAXIMIANO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processados como incurso no artigo 33 c.c. o artigo 40, inc. III, da Lei n.º 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 9 de setembro de 2020, por volta das 19 horas e 10 minutos, na rua Copo de Leite nº 175, bairro Jardim Planalto, nesta cidade e comarca, CARLOS trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 142 eppendorfs contendo cocaína, em pó, com peso bruto aproximado de 121,6g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. fotografia de fls. 11 e laudo de constatação de fls. 13/16). Apurou-se que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local mencionado, quando avistaram CARLOS na via pública. Notando a aproximação dos PMS, o indiciado correu e dispensou a sacola plástica que tinha em seu poder, o que foi notado pelos servidores públicos. O denunciado foi perseguido e alcançado. Os policiais recolheram a sacola plástica dispensada por CARLOS e constataram que ela continha 142 porções de cocaína 2. O processo teve trâmite regular, cf. fls. 75, 119, 140 e 141/142. 3. A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 7/9, depoimentos colhidos e, especialmente, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10 e laudos de constatação de fls. 13/16 e toxicológico de fls. 82/84. 4. A autoria também foi determinada na prova oral coligida. Os PMS Morasco e Graziano contaram, em uníssono, que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um indivíduo andando sozinho pela via pública. Ao avistar os policiais o acusado acelerou o passo e dispensou um objeto na via, visando ocultá-lo. Enquanto o PM Carlos deteve o acusado, o PM Graziano retornou para buscar o objeto dispensado, constatando-se as 142 porções de cocaína. Em juízo, o subtenente acrescentou que o réu deu de frente com a viatura. Nessa situação, ele soltou o saco plástico em que havia as drogas. O acusado não era da cidade, conforme ficou apurado posteriormente. Ele não era conhecido. Já o policial Graziano, corroborando as informações de seu colega, disse que o réu subia a viela na direção da viatura. Ele deixou cair ao solo uma sacolinha transparente. O acusado foi abordado e não tinha nada de ilícito. Verificando a sacolinha, encontrou dentro dela outras duas sacolas, com mais de 100 porções de droga. No interrogatório policial, CARLOS afirmou que foi até o local e comprou crack de duas pessoas desconhecidas. Quando retornava para casa foi abordado pela polícia e só tinha em sua posse duas pedras de crack. Negou a propriedade das demais substâncias que os policiais encontraram. Perante a MMA. Juíza, o réu continuou negando os fatos. Informou que foi abordado e que tinha em seu poder quatro porções de maconha, que lhe pertenciam e eram destinadas ao uso próprio. Quando "viu os home", dispensou a maconha, que estava em "paranguinhas" na sua mão. Eles encontraram a sacolinha com as drogas no mesmo local, mas tais drogas não lhe pertenciam. Apesar da negativa do réu sobre a propriedade da droga, ficou evidente, nos depoimentos dos servidores públicos, que o réu foi surpreendido com as porções de droga. Não há razão para duvidar do que disseram. De fato, nossas Cortes de Justiça avalizam os depoimentos de policiais (e guardas civis por extensão), forte no entendimento de que seria um contrassenso cometê-los da difícil missão de atuar na prevenção e repressão de crimes para, em seguida, negar validade a seus relatos, justamente quando prestam conta em Juízo de seu sensível trabalho (sobre a validade da palavra dos policiais,

cf. TJ-SP - APL: 0000162-52.2013.8.26.0547, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 06/11/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/11/2014). No panorama dos autos, a condenação é de rigor. A quantidade e a forma de apresentação das drogas revelam sua destinação para o tráfico. 5. No tocante à aplicação da pena, verifica-se que CARLOS não possui antecedentes desabonadores. 6. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). CARLOS EDUARDO MAXIMIANO foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme os fatos narrados na inicial acusatória. Recebida a denúncia, o feito teve seu regular trâmite, sendo encerrada a instrução na presente audiência. O Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Ocorre, contudo, que a ação penal deve ser julgada improcedente. Excelência, inicialmente é preciso reconhecer que não há provas que permitam concluir, com segurança, que o réu incorreu no crime de tráfico de entorpecentes que lhe foi atribuído. Na fase policial, o acusado negou a prática delitiva. Afirmou que era residente em Mogi-Guaçu, mas que estava trabalhando em Piracicaba, cidade em que também passou a morar, no Bairro Jardim Vitória. Não conhecia bem a região, mas por indicação de amigos esteve no local para comprar crack. Ali comprou porções de duas pessoas desconhecidas. Posteriormente, no entanto, acabou abordado por policiais militares. Estava em poder de apenas duas pedras de crack, desconhecendo as demais apreendidas. Nesta audiência, sob o crivo do contraditório, voltou a negar o tráfico. Foi abordado pelos policiais na ocasião. Foi ao local para comprar quatro porções de maconha, por vinte reais. Quando os policiais o viram, dispensou a maconha. Os policiais não acharam a maconha, mas sim os "pinos", os quais não lhe pertenciam. Ainda durante a persecução penal foram ouvidos os dois policiais militares responsáveis por sua prisão. Na fase informativa, Carlos Alberto Morasco e Graziano Ciola Dias declararam que faziam patrulhamento ostensivo no local dos fatos quando avistaram um indivíduo andando sozinho pela via pública. Este, no entanto, ao visualizar a viatura policial, acelerou o passo e dispensou um objeto na via, o qual posteriormente souberam se tratar de uma sacola contendo cento e quarentas e duas porções de cocaína. O réu, segundo eles, não admitiu o crime. Judicialmente, os policiais acrescentaram que depois apuraram que o réu não era morador de Piracicaba. Ou seja, como se nota, a prova que incrimina o acusado é bem frágil, na medida em que só foram ouvidos os responsáveis pela sua prisão que, evidentemente, são testemunhas parciais. Afinal, não há como negar que os depoimentos dos policiais militares estão contaminados pela atuação que tiveram na apuração dos fatos, o que gera a necessidade de justificar os atos praticados. Assim, ainda que não estejam impedidos de depor, certo é que seus testemunhos devem ser recebidos com cautela, sobretudo no momento de se conferir o devido valor probatório. Não é por outra razão que em diversas ocasiões já se decidiu pela impossibilidade de se fundamentar uma condenação apenas com base na palavra dos responsáveis pela persecução penal: "As palavras dos policiais merecem credibilidade, mas não basta o título (exercício da função de policial). Há necessidade de que estas tenham apoio em evidências circunstanciais e testemunhais, sob pena de exaltar-se um registro indiciário como absoluto, infalível e inquestionável". (TJSP - 7ª Câm. - Ap. Cr. n. 1.465.651/6 - Com. de Campinas - j. 19/5/2005 - v.u.). No mesmo trilha ensina o professor Gustavo Henrique Badaró (os destaques são nossos): "Quanto aos depoimentos dos policiais, há correntes radicais, que, pelo seu próprio extremismo, devem ser descartadas. Uma dessas correntes entende que o fato de a testemunha ser policial, por si só, não a torna impedida de depor, não havendo qualquer disposição legal neste sentido. Ao contrário, o policial não se enquadra nas hipóteses do art. 207 do CPP, devendo ser dado ao seu depoimento o mesmo valor de qualquer outra testemunha. De outro lado, há corrente oposta, no sentido de que os policiais, pela simples condição funcional, seriam suspeitos. Deve prevalecer uma corrente intermediária: se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelo simples fato de serem policiais, por outro lado, é inegável o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de provas existentes nos

autos, em especial o testemunho de pessoas estranha aos quadros da polícia. Não se pode esquecer que as testemunhas são, por definição, terceiros imparciais, sem qualquer interesse no processo, o que não é exatamente o caso dos policiais em relação aos crimes por eles investigados. Por tais motivos, não se deve admitir que seja proferida uma sentença condenatória com base exclusiva no depoimento de policiais, ainda que estes se mostrem harmônicos entre si". (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 588). E, no caso sob análise, para além dos depoimentos dos agentes integrantes aos quadros da segurança pública, nenhuma outra prova foi produzida. Na verdade, observa-se que os policiais nada disseram sobre eventual ato suspeito praticado pelo réu, resumindo-se a relatar que ele dispensou as drogas, versão que é repetida em diversas ocasiões pelos milicianos. O réu, por sua vez, mostrou-se sincero quando foi ouvido, custando crer ainda que alguém recém-chegado à cidade estaria traficando. Veja que a versão do acusado de que é morador de outra cidade é corroborada pela certidão do oficial de justiça, que o intimou em Mogi-Guaçu. Chama a atenção ainda que com o réu nenhum dinheiro foi encontrado. Assim, verifica-se que as provas produzidas contra o réu são bem precárias, ainda mais considerando o crime que lhe é atribuído, equiparado a hediondo. Não se quer dizer que os policiais mentiram, mas apenas que, para a condenação, prova mais robusta é necessária. A propósito, cumpre registrar que quanto mais se dá crédito a esse tipo de prova, mais se incentiva a precariedade de investigações, o que pode dar azo a abusos e manipulações. Assim, mostrando-se frágil o conjunto probatório, requer-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. No entanto, caso o entendimento de Vossa Excelência seja diverso, em caso de condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes requer-se a fixação da pena no mínimo legal, considerando que não houve apreensão significativa de entorpecente O réu, ademais, é absolutamente primário. Já na terceira fase é o caso de aplicação da causa redutora de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois preenchidos todos os requisitos legais. O réu é primário, não há prova que integre organização ou associação criminosa. Apresentou nesta data comprovação de que trabalho. Assim, presentes os requisitos legais para aplicação da causa minorante, a pena do réu deve ser reduzida em patamar máximo, o que, por consequência, autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44, do Código Penal. Por fim, caso não se aplique a causa redutora de pena, requer-se que, ao menos, seja estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, bem como seja garantido o direito de recorrer em liberdade, já que não subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

CARLOS EDUARDO MAXIMIANO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 9 de setembro de 2020, por volta das 19,10 horas, na rua Copo de Leite nº 175, bairro Jardim Planalto, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 142 "ependorfs" contendo cocaína, em pó, com peso bruto aproximado de 121,6g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. fotografia de fls. 11 e laudo de constatação de fls. 13/16).

Narra a denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local mencionado, quando avistaram Carlos na via pública. Notando a aproximação dos PMS, o réu correu e dispensou a sacola plástica que tinha em seu poder, o que foi notado pelos servidores públicos. O acusado foi perseguido e alcançado.

Os policiais recolheram a sacola plástica dispensada por Carlos e constataram que ela continha 142 porções de cocaína.

Conclui a denúncia que a quantidade, o fracionamento, a forma do acondicionamento e as circunstâncias do flagrante evidenciaram que as substâncias apreendidas se destinavam ao tráfico.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 113). Defesa preliminar apresentada às fls. 116/117. Após, a denúncia foi recebida (fls. 119) e

o réu foi citado (fls. 140).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa pediu a absolvição, sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado. No caso de condenação, a aplicação do privilégio.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) Boletim de ocorrência de fls. 07/09;
- 2) Auto de exibição e apreensão de fls. 10 e fotografia de fls. 11;
- 3) Laudo de constatação de fls. 13/16 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 82/84, com resultado positivo para cocaína em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 04), o réu negou o crime. Declarou que residia na cidade de Mogi Guaçu e estava trabalhando em Piracicaba para uma empresa de nome "Jaguari". Disse que estava residindo perto de um pesqueiro, próximo ao bairro Jardim Vitória, mas não soube informar o local exato. Na data dos fatos foi ao local comprar "crack" de duas pessoas que não conhecia, sendo que o local era conhecido como ponto de tráfico e foi indicado por amigos. Quando estava retornando para casa foi abordado pela polícia militar. O ponto de drogas ficava a alguns metros de onde foi abordado. Ademais, afirmou que somente estava na posse de duas pedras de "crack" e desconhecia o restante das drogas que os policiais disseram ter sido encontrado em sua posse.

Interrogado em juízo (gravação), o acusado negou o crime. Disse que, no dia dos fatos, comprou, para seu uso, quatro porções de maconha, por R\$ 20,00. Logo após, viu os policiais e dispensou as drogas ao solo. Os policiais encontraram uma sacola contendo as 142 porções de cocaína na mesma rua onde foi abordado e imputaram-lhe a posse de tais drogas. Estava em Piracicaba em razão do trabalho numa empresa que fazia um loteamento nesta cidade.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 02) e em juízo (gravação), o policial militar Carlos Alberto Morasco declarou que estavam em patrulhamento ostensivo de rotina pelo Bairro São José quando, durante a ronda, avistaram o réu andando sozinho pela via pública e viram que, ao avistar a viatura, ele acelerou o passo e dispensou um saco plástico no chão. Diante disso, abordaram-no e, em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado em sua posse, estando ele com apenas um celular. Recolheram o saco jogado ao solo pelo réu e constataram que continha 142 porções de cocaína. O acusado não assumiu a propriedade das substâncias que estavam na sacola que ele próprio dispensou, fato presenciado por toda sua equipe. Ele também não quis fornecer seu endereço no momento dos fatos, só tendo declarado seus dados na delegacia de polícia. Por fim, disse que, pelo apuraram, ele não morava em Piracicaba.

No mesmo sentido as declarações do policial militar Graziano Ciola Dias na delegacia de polícia (fls. 03) e em juízo (gravação).

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a uma pessoa a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confirmam-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSO JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos policiais militares: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 142 "ependorfs" contendo cocaína, substância esta que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De fato, sua negativa foi afastada pelos uníssonos e convergentes depoimentos dos policiais militares no sentido que viram o acusado dispensando a droga com as drogas após ele notar a presença da viatura policial.

A quantidade de drogas indica o destino comercial, sendo totalmente incompatível com a situação do mero usuário. Some-se a tudo isso o fato de as drogas estarem fracionadas e acondicionadas em porções individuais, como comumente são comercializadas (fotografia de fls. 11).

Ademais, ainda que se considerasse a possibilidade de o acusado ser usuário de drogas, como ele alegou, a condição de usuário não é inconciliável com a traficância, pois não é incomum usuários traficarem para sustentarem o próprio vício e ainda obterem algum lucro.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO." (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

"MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos

entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

O réu é primário e possui bons antecedentes (cf. F.A. de fls. 37/38 e certidões de fls. 34).

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis, de modo que lhe aplico as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento.

Presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário, de bons antecedentes e não há notícias de que integre organização criminosa ou se dedique exclusivamente às atividades criminosas, reduzo as penas em 2/3, perfazendo um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

Quanto ao regime de fixação da pena, o entendimento que vinha sendo adotado por esta magistrada era de que o único compatível com o grave crime em questão, que traz nefastas consequências para a sociedade, era o fechado.

No entanto, decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 118.533/MS, reconheceu a figura privilegiada nos crimes de tráfico de drogas nos casos de "envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa" (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016), hipótese dos autos.

Referida decisão foi referendada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que, revendo entendimento anteriormente consolidado naquela corte, cancelou o enunciado 512 da Súmula, afastando a hediondez no crime de tráfico privilegiado.

Essas Cortes Superiores têm reiteradamente pronunciado que o tráfico privilegiado, se não forem desfavoráveis ao réu as circunstâncias em que cometido, comporta regime aberto para início do cumprimento da pena e permite sua substituição por restritivas de direitos.

Assim, rendendo-me a tais posicionamentos e, considerando que todas as circunstâncias do crime praticado pelo réu, o qual é primário, lhe favorecem, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena corporal.

Pelos mesmos motivos, substituo tal pena por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções.

Elegi duas restritivas de direitos porque a pena substituída é superior a um ano (CP, art. 44, parágrafo 2º) e em razão da maior gravidade do crime, que fomenta a prática de vários outros delitos, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que não conseguem se livrar do vício.

Neste contexto, substituição por apenas uma pena restritiva de direitos e por uma pena pecuniária muito provavelmente não fariam com que o réu sentisse as graves consequências de seu ato e não seriam suficientes para impedir que continuasse a realizar o nefasto comércio.

Em casos como este, é necessária resposta firme do Estado para que a pena cumpra suas funções de prevenção e reprovação dos crimes.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, eis que ausentes elementos que demonstrem a situação financeira do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu CARLOS EDUARDO MAXIMIANO a cumprir um ano e oito meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a entidade assistencial da

comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de decretá-la e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo Representante do MP, RÉU e DEFESA foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida.

Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se o necessário. Oportunamente, archive-se.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.